

1500084-72.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Simone Rodrigues Valle

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... de que o suposto veículo envolvido com o tráfico de drogas estava na cidade e havia adentrado no condomínio, evidente que há informações sobre a prática do crime, bastando para excepcionar a inviolabilidade domiciliar.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico encontra-se totalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500084-72.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500084-72.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2014984/2022 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA, 22494774 - 01º

D.P. BRAGANÇA PAULISTA, 2014984 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JÉRISSON WASHINGTON NICOLAU DA SILVA SANTOS e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Simone Rodrigues Valle

Vistos.

BRUNO REIS CARDOSO XAVIER e JÉRISSON WASHINGTON NICOLAU DA SILVA SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, todos da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 17 de janeiro de 2022, às 16:00 horas, na Rua Vicente Manoel Aricó, 1, Curitiba, nesta cidade e Comarca, os acusados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo para venda, fornecimento ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, 490 (quatrocentos e noventa) papétes de cocaína, pesando aproximadamente 440g (quatrocentos e quarenta gramas), 01 (um) tijolo de crack, pesando aproximadamente 400g (quatrocentos gramas), 05 (cinco) tijolos de maconha, pesando aproximadamente 4kg (quatro

quilogramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como um telefone celular, marca Apple, 07 (sete) sacos com embalagens plásticas pertencentes a Bruno e 01 telefone celular, marca Motorola, pertencente a Jérisson. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, os acusados associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11343/2006.

Os acusados foram devidamente notificados e ofereceram defesas escritas às fls. 190/191 e fls. 1197/192.

Após, a denúncia foi recebida em 11 de março de 2022, às fls. 222/225, sendo os réus devidamente citados.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes. Após, os réus foram interrogados (fls. 275).

Encerrada a instrução, os debates orais foram convertidos em memoriais, oportunidade em que o Ministério Público requereu procedência da ação, nos exatos termos da denúncia, manifestando-se acerca da dosimetria da pena (fls. 279/285). A Defesa do acusado Jérisson se manifestou às fls. 287/292. Requereu a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso V, do CPP. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, ou o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Por fim, a Defesa do acusado Bruno se manifestou às fls. 294/302. Inicialmente, alegou a nulidade da prova, considerando o ingresso no imóvel sem mandado. No mérito, requereu a absolvição do acusado com relação ao crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, incisos IV e V, do CPP. Com relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, requereu a fixação da pena em seu patamar mínimo, o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, o reconhecimento do tráfico privilegiado com aplicação do redutor na fração máxima, fixação de regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade.

Trata-se o crime de tráfico de drogas de crime permanente, ou seja, crime em que a execução e consumação se prolongam pelo tempo, bem como também se estende o estado de flagrante delito.

Assim, por ser crime permanente, sua execução possibilita a entrada no domicílio onde estiver sendo praticado, enquanto perdurar o estado de flagrância, independentemente de autorização do morador (art. 5º, XI, CF).

Interpretando a norma constitucional (art. 5º, XI, CF), o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Especial nº 603.616/R0, julgado sob o regime de repercussão geral, estabeleceu que, havendo elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, é possível excepcionar a regra constitucional da inviolabilidade domiciliar.

Leia-se: (...) Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida (...). (STF; Tribunal Pleno; RE 603.616/R0; Relator: Ministro Gilmar Mendes; j. 05.11.2015).

Assim, diante da notícia de que o suposto veículo envolvido com o tráfico de drogas estava na cidade e havia adentrado no condomínio, evidente que há informações sobre a prática do crime, bastando para excepcionar a inviolabilidade domiciliar.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico encontra-se totalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante às fls. 05, pelo boletim de ocorrência de fls. 41/43, auto de exibição e apreensão às fls. 23/24, pelo laudo de constatação preliminar às fls. 19/20 e, em especial, pelos laudos de exame químico toxicológico (fls. 176/178,

179/181 e 182/184) que apontoaram resultados positivos para tetrahydrocannabinol e cocaína.

A autoria dos acusados, por sua vez, restou comprovada para o crime de tráfico de drogas.

Na fase policial, os acusados permaneceram em silêncio.

Em juízo, o acusado Bruno confessou os fatos. Relatou que estava guardando o entorpecente, a saber: maconha, cocaína e crack, pois estava com uma dívida com uma pessoa de São Paulo. Quanto ao corréu, disse que estava no local apenas para fazer uso de maconha e que não estavam fracionando a droga. Conheceu o réu Jérisson há uns dois anos em uma festa em Bragança e disse que ele não sabia que havia mais drogas no local. Informou que o veículo foi presente de seu pai e que a casa em construção era também de seu pai. Afirmou ser usuário de drogas há um bom tempo e já ter feito tratamento. Relatou que uma pessoa mandou entregar as drogas no local e que seria retirada no dia seguinte e, dessa forma, estaria paga sua dívida. Negou ter feito uso de seu veículo para transportar droga.

O acusado Jérisson, em juízo, negou a prática do crime de tráfico de drogas. Disse que o réu Bruno passou na sua casa e foram até o condomínio fazer uso de maconha e logo já chegaram os policiais. Conhecia o acusado de festas, mas não se viam com frequência. Negou estar fracionando a droga e disse que não viu droga no local, tendo permanecido no cômodo onde estava fazendo uso da maconha.

A testemunha Marcos Severiano de Oliveira, policial civil, disse que havia uma investigação, pois tinham a informação de que veículo da marca Audi, de placa desconhecida até o momento, trazia drogas de São Paulo para um condomínio na região de Bragança Paulista para posterior distribuição. A investigação durou cerca de dez dias e, no dia dos fatos, souberam que o possível carro estaria na região dos condomínios. Foram até o local, onde existem dois condomínios, e souberam que o veículo entrou em um deles. Adentraram no condomínio e visualizaram o veículo estacionado em frente a uma construção abandonada. De imediato entraram na construção, que estava aberta, e se depararam com os réus manipulando as drogas. Relatou que havia bastante droga onde se encontravam os réus e distribuídas nos demais cômodos, tratando-se de maconha, uma porção de crack maior e cocaína fracionada. Os réus nada disseram. Disse que souberam acerca do veículo e dos condomínios tanto por denúncias anônimas como por informações policiais. Não conhecia os acusados e, posteriormente, um deles disse que residia na cidade e outro que já residiu, mas que agora morava em São Paulo. A construção pertencia ao pai do acusado Bruno, assim como o veículo. Relatou que nenhum tipo de material relacionado ao uso de drogas foi encontrado, somente para o preparo e distribuição. No mesmo sentido foi o depoimento do também policial civil, Leandro José Barbosa, que acrescentou que a informação acerca de que o veículo estaria sendo utilizado para o tráfico veio das delegacias dos policiais, dando conta apenas do modelo do veículo e do condomínio. Disse que o réu Bruno informou que teria ganhado o veículo de seu pai para trabalhar como Uber, enquanto o Jérisson disse que estava no local para consumir droga. Relatou que chegaram no local aproximadamente 20 minutos após o veículo.

Inicialmente, anoto que deve ser dado expressivo valor aos relatos apresentados pelos policiais ouvidos, pois não ficou demonstrado qualquer indício de sentimento pessoal de parte daqueles que efetivaram a prisão dos acusados em prejudicá-los sem qualquer elemento concreto nesse sentido.

Ademais, nada indica que os policiais civis tenham criado alguma situação para acusar falsamente os acusados, não havendo nos autos qualquer elemento que comprove a implantação de drogas.

Registre-se, ainda, que a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais e guardas, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada a má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

“TÓXICO. Tráfico. Insuficiência probatória. Inocorrência. Condenação fundada em testemunho de policiais. Validade. Depoimentos firmes e coerentes. Materialidade

devidamente comprovada. Recurso não provido." (Apelação Criminal nº 229.463-3 Guarujá 2ª Câmara Criminal 03.11.97. V. U.).

"TÓXICO. Tráfico. Caracterização. Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Inadmissibilidade. Solução condenatória lastreada exclusivamente na palavra de policiais. Inocorrência. Depoimentos válidos, encontrando amparo em outros elementos do processo. Relatos, ademais, que merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Recurso não provido. Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando, sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial." (Apelação Criminal nº 189.074-3 Palmital 1ª Câmara Criminal 02.10.95 V. U.).

Assim, ao término da instrução processual, verifica-se que a autoria do crime de tráfico imputada aos acusados restou devidamente comprovada.

Certo que, policiais civis iniciaram investigação sobre a ocorrência da traficância em um condomínio da região envolvendo um veículo Audi, responsável pelo transporte da droga.

No dia dos fatos, foram informados acerca da entrada do referido veículo na cidade. Diligenciaram na região do condomínio e o localizaram estacionado em frente a uma construção.

No interior da construção, depararam-se com os réus manuseando entorpecentes, tendo sido encontrada grande quantidade de droga, como maconha, uma porção de crack maior e cocaína fracionada.

O acusado Bruno confessou que guardava o entorpecente por conta de uma dívida, no entanto, negou que o réu Jérisson sabia da existência das drogas, afirmando que eles estavam no local tão somente para fumar maconha.

No mesmo sentido é a versão do réu Jérisson que, ainda, negou estar manuseando qualquer entorpecente quando da chegada policial.

Porém, em que pese sua negativa, sua versão não convence. Como já dito, não há qualquer motivo para que as declarações dos policiais sejam afastadas, não havendo qualquer indício de que tenham qualquer intenção de prejudicar o acusado.

Os policiais confirmaram que abordaram os acusados quando manipulavam os entorpecentes e que não localizaram objetos relacionados ao uso de drogas e que tampouco eles estariam usando drogas.

Desse modo, é certa a posse da droga por parte dos acusados, restando analisar a sua finalidade e a outra conclusão não se chega senão a finalidade mercantil.

Com efeito, a expressiva quantidade e a diversidade das drogas, além das embalagens encontradas para o armazenamento para posterior comercialização dos entorpecentes, sendo certo que eles foram surpreendidos fracionando as drogas, indicam a sua finalidade mercantil.

Ademais, os policiais chegaram até os réus em razão das investigações pretéritas, no sentido de que um veículo importado estaria fazendo o transporte de drogas.

No mais, a alegação da defesa de que o acusado Jérisson seria usuário não prospera. É certo que nenhuma porção ou cigarro de maconha foram encontrados a fim de corroborar a versão de que os acusados estariam no local para usar entorpecente.

Ao contrário, foi encontrada grande quantidade de droga, dentre elas, inclusive, 5 tijolos de maconha pesando 4 quilos, quantidade incompatível à condição de usuário. Ainda que assim fosse, a mera alegação de que é usuário não tem o condão de permitir a desclassificação, conforme pretendido, pois como é sabido, normalmente encontram-se em uma mesma pessoa as figuras de usuário e traficante, sem que com isso saia ileso do crime de maior gravidade.

E todas as circunstâncias do caso em concreto, como já dito acima, comprovam a sua finalidade mercantil, não havendo que se falar em insuficiência de provas, de modo que as versões dos réus restaram isoladas nos autos.

Portanto, de rigor a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas.

Por outro lado, improcede a acusação quanto ao crime do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06. Para a configuração do crime é necessário que se verifique que a associação é estável e permanente para o fim da prática dos ilícitos descritos no

artigo 33 da referida lei.

No presente caso, as investigações tiveram início diante da informação de que um veículo importado estaria sendo utilizado para o transporte das drogas, de modo que, somente na abordagem, foi conhecida a identidade dos acusados. Os policiais não conheciam os réus e tampouco já tinham visto os dois anteriormente. O veículo, por sua vez, somente foi avistado no dia do ocorrido.

Portanto, as provas dos autos são frágeis para o reconhecimento de uma associação entres eles, havendo tão somente um esforço comum para a prática do crime.

E havendo qualquer resquício de dúvida, de rigor a aplicação do princípio "in dubio pro reo", com a absolvição pelo delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Resolvido o mérito, passo à dosimetria da pena para os acusados.

Na primeira fase da dosimetria da pena, não verifico circunstâncias judiciais que justifiquem a elevação da pena acima do mínimo legal, motivo pelo qual fixo a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no valor unitário mínimo legal para os acusados.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, pelo que mantenho a pena acima fixada. Anoto aqui que não há que se falar em reconhecimento da atenuante para o acusado Bruno, já que ela não foi total, pois apesar de confessar a prática do crime, disse que não utilizou o veículo para o transporte da droga, afirmando ainda que o corréu Jérisson estava no local somente para usar entorpecente. Somente a confissão total pode beneficiar o réu.

Mudando entendimento anterior, na terceira fase, não verifico como recomendável seja aplicada a causa de diminuição contida no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Com efeito, o artigo em comento trata da figura do "traficante privilegiado", também chamada de "traficância menor" ou "traficância eventual, no qual estabelece a redução de pena de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

Quanto aos réus, apesar da primariedade, as circunstâncias da prisão, considerando a quantidade significativa de droga apreendida (mais de 4 kg de droga), bem como à sua variedade (maconha e cocaína), dão conta de que os réus não realizavam a mercancia ilícita de forma ocasional. Tanto assim é que estavam fracionando a droga no momento da abordagem, não se mostrando cabível, portanto, a aplicação do referido benefício.

Ressalto, ainda, que a quantidade de droga apreendida não foi considerada como circunstância judicial, sendo considerada nesta fase para impedir a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º a fim de se evitar bis in idem.

Nesse sentido, o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar em 19.12.2013 os "Habeas Corpus" nºs 112.776/MS e 109.193/MG, ambos de relatoria do Ministro Teori Zavascki, decidiu que "em caso de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza e a quantidade da droga apreendida apenas podem ser levadas em consideração em uma das fases da dosimetria da pena, sendo vedada sua apreciação cumulativa". Na ocasião, ficou consignado que "cabe ao juiz escolher em qual momento da dosimetria essa circunstância vai ser levada em conta, seja na primeira, seja na terceira, observando sempre a vedação ao 'bis in idem'".

Assim, torno definitiva, para os acusados, a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no valor unitário mínimo legal, diante da ausência de causas modificadoras.

Pela quantidade da pena, não há que se falar em aplicação do artigo 44 ou 77 do Código Penal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista que não se trata de tráfico privilegiado, equiparando-se ao crime hediondo, bem como a quantidade da pena aplicada, fixo o regime FECHADO para início de cumprimento de pena.

Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que o Ministério Público move contra BRUNO REIS CARDOSO XAVIER e JÉRISSON WASHINGTON NICOLAU DA SILVA SANTOS, qualificados nos autos, para CONDENÁ-LOS à pena de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa no valor unitário mínimo legal, em regime inicial fechado, como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. ABSOLVO os

acusados da imputação prevista no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Verifico que os requisitos da prisão preventiva estão presentes, sobretudo a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, motivo pelo qual mantenho a prisão preventiva já decretada.

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram recolhidos por força desta sentença e expeçam-se guias de recolhimento provisória, caso haja recurso por qualquer das partes.

Tendo em vista que restou apurado que o veículo apreendido era utilizado para a prática do crime de tráfico, decreto o seu perdimento em favor da União, expedindo-se o necessário.

Quanto aos celulares, considerando que nada foi apurado relativo ao seu uso na prática do tráfico de drogas, determino a restituição em favor dos acusados.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Bragança Paulista, 31 de maio de 2022.

Simone Rodrigues Valle

Juíza Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA